

1502016-28.2022.8.26.0438

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

1ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502016-28.2022.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502016-28.2022.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ALVES TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra MARCOS ALVES TEIXEIRA, devidamente qualificado(a) nos autos, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (fls. 73/16). O(a) réu(ré) foi devidamente notificado(a), apresentando resposta escrita às fls. 87/93

Denúncia recebida em 01 de novembro de 2022, conforme decisão de fl. 98/99

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram inquiridas testemunhas arroladas pelas partes, sendo, em seguida, interrogado o acusado. Após, o(a) representante do Ministério Público e o(a) defensor(a) apresentaram alegações finais orais.

Os autos me vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, “Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)” (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No caso do delito de tráfico de drogas, são indícios suficientes para a condenação do(a) agente, dentre outros: a) a confissão da prática do crime; b) a apreensão de substância entorpecente em poder do(a) autor(a) do fato e/ou de dinheiro em espécie (normalmente fracionado em notas miúdas, não possuindo o(a) denunciado(a) explicação convincente para a origem do numerário), bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes; e) a circunstância de o(a) acusado(a) ser conhecido no meio policial como traficante de drogas, responder a inquérito, já ter sido ou estar sendo processado, e/ou possuir condenação pela prática do referido delito. Em tais casos, ainda que o(a) autor(a) do fato não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, esses indícios (prova indireta) permitem que o magistrado conclua, em processo indutivo, ser ele(ela) traficante de drogas.

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição, apreensão, constatação e entrega (fls. 10), laudo de constatação prévio (fls. 14/17), pelos laudos periciais definitivos (fls. 59/64 e 101/103) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Conforme narrado na denúncia, no dia 13 de setembro de 2022, por volta das por volta de 8h, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), km.287, o denunciado MARCOS ALVES TEIXEIRA transportava, entre estados da federação e para repasse a terceiro, 18 (dezoito) tabletes de maconha, pesando 13,995kg (laudos de fls. 14/17 e 59/61),

substância Tetrahydrocannabinol, constituinte ativo do vegetal Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais militares rodoviários faziam patrulhamento de rotina na citada rodovia, quando abordaram o ônibus da empresa Motta que fazia o trajeto Campo Grande/MS-Brasília.

O denunciado era um dos passageiros e apresentou nervosismo na verificação.

Indagado a respeito da bagagem, se havia algo de errado, o denunciado confessou aos policiais que transportava dezoito tijolos de maconha. Desceram do ônibus e o denunciado lhes apontou sua mala, que coincidia com a numeração do comprovante de bagagem. Em seu interior, os policiais encontraram dezoito tabletes mencionados pelo acusado acondicionados dentro de sacos de lixo cobertos com pó de café, provavelmente para ocultar o cheiro da droga.

O denunciado confirmou que reside em Parauapebas/PA, que buscou a droga em Campo Grande/MS e que a deixaria na rodoviária de sua cidade. Pelo transporte, receberia R\$ 1.000,00 (mil reais). Evidente, portanto, que o denunciado transportava droga para fim de tráfico, de Campo Grande/MS para Parauapebas/PA.

Vejamos.

O(a) acusado(a) MARCOS ALVES TEIXEIRA, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que "reside na cidade de Parauapebas-PA; saiu de sua cidade na última quinta-feira e foi para Campo Grande-MS, buscar a droga apreendida; que em sua cidade envolveu em uma briga e foi ameaçado de morte; uma pessoa desconhecida que lhe defendeu, lhe pediu o favor de buscar a droga; foi buscar e na cidade de Campo Grande, recebeu a droga de uma pessoa também desconhecida, não sabendo a quantidade, sabendo apenas ser maconha; deixaria a mala na rodoviária de sua cidade, onde receberia a importância de um mil reais; viajava no ônibus da Empresa Motta, quando foi parado por policiais militares, oportunidade que confessou o transporte; não tem filhos; nunca foi processado" (fl. 04).

Na audiência de instrução e julgamento, o(a) denunciado(a) MARCOS ALVES TEIXEIRA confessou a autoria delitiva. Sustentou que tem 20 anos de idade e é natural de Belém/PA. Indagado, disse que um amigo interveio para o defender de uma briga. Em troca, esse amigo o pediu para buscar drogas em Campo Grande/MS e leva-la até Parauapebas/PA. Pegou a droga com um indivíduo em um hotel, que lhe entregou uma mala. Não abriu a mala e foi até a rodoviária. Pegou o ônibus para Minas Gerais e de lá iria pegar outro ônibus para o Pará. Iria receber R\$ 1.000,00. Não é usuário de drogas. Foi a primeira vez que se envolveu em um delito. Nunca tinha saído de seu estado natal. O valor de R\$ 1.000,00 seria para custear suas despesas.

A(s) testemunha(s) FAUSTO BENEDITO DOS SANTOS e VINÍCIUS AMOROSO ANDREAZZI, policiais militares, em solo policial, disseram que "nesta data estava em patrulhamento na Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), km. 287, neste município, juntamente com outros policiais, quando sinalizaram para parar um ônibus da Empresa Motta, que fazia o trajeto Campo Grande-MS - Brasília-SP; entrevistando os passageiros, o indiciado aqui presente apresentou nervosismo e primeiro disse que retornava da casa de sua mãe, na cidade de Campo Grande-MS e rumava para Parauapebas-PA; depois disse que transportava apenas uma mochila; verificando a mochila, que havia poucas peças de roupas, havia também um comprovante de bagagem, que estava no bagageiro do ônibus; indagado novamente a respeito da bagagem se havia algo de errado, este confessou que transportava dezoito tijolos de maconha; desceram do ônibus e o indiciado mostrou a mala, que coincidia com a numeração do comprovante de bagagem, constatando que realmente no interior continha dezoito tabletes de maconha, dentro de sacos de lixo, cobertos com pó de café, provavelmente para não ficar o cheiro da maconha; o indiciado disse ainda que estava sendo ameaçado em sua cidade e que uma pessoa lhe prometeu dar segurança, mas em troca, deveria ir até a cidade de Campo Grande-MS buscar a droga e ao final, ainda receberia a importância de um mil reais; foi para Campo Grande-MS, onde um desconhecido lhe entregou a droga; deu-lhe voz de prisão e o conduziu a esta unidade, sem o uso de algemas. Em tempo, em obediência ao art. 304 do CPP, emprestou a Autoridade, neste ato, RECIBO pela entrega do capturado, determinando, com os recursos disponíveis (ressalvada a hipótese de colaboração espontânea de

outras instituições) a custódia do agente em dependência designada, dotada de suficiente vigilância acauteladora para ulterior encaminhamento ao sistema prisional" (sic) (fl. 02/03).

Ao serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas FAUSTO BENEDITO DOS SANTOS e VINÍCIUS AMOROSO ANDREAZZI sustentaram que estavam realizando fiscalização e abordaram um ônibus com itinerário Campo Grande/MS – Brasília/DF. No interior do ônibus fizeram entrevista com passageiros. Ao entrevistarem o réu, perceberam nervosismo anormal da parte dele. Indagado, ele disse que vinha de Campo Grande/MS e estaria visitando a mãe dele. Perguntaram informações sobre a genitora do acusado, porém ele disse que não tinha essa informação. O réu trazia consigo no ônibus uma mochila e uma mala no bagageiro. Na mochila havia apenas objetos pessoais e um tíquete da mala que estava no bagageiro. Foram até o bagageiro e ele apontou a mala. Ao abrirem a mala, localizaram 18 tijolos de maconha. Indagado sobre a origem e destino da droga, o acusado disse que estava sendo ameaçado na cidade onde ele mora e que uma pessoa teria lhe oferecido proteção. Em troca, essa pessoa teria pedido ao réu que ele fosse até Campo Grande, pegasse a droga e transportasse o entorpecente a cidade de Paraupabas/PA. O réu não deu detalhes sobre quem o estaria ameaçando ou quem lhe teria oferecido segurança em troca do transporte das drogas.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Além disso, é fato notório e de conhecimento geral que, nos crimes (e atos infracionais) de tráfico de drogas, impera a lei do silêncio, haja vista que a(s) testemunha(s) do fato, sentindo-se amedrontada(s) e temendo por sua integridade física e/ou de seus amigos e familiares, optam por se calar, por fornecer pouco(s) detalhe(s) a respeito da empreitada criminosa ou, simplesmente, por mentir à autoridade policial e/ou ao(à) magistrado(a). Em tal contexto, a(s) denúncia(s) anônima(s) e o(s) depoimento(s) de policiais civis e militares possuem grande valor probatório.

5. A defesa requer o afastamento da culpabilidade, com fundamento na causa supralegal da inexigibilidade de conduta diversa. Argumenta que o acusado não possuía liberdade para agir, em razão de sua instabilidade emocional e vulnerabilidade financeira. Ademais, ele jamais havia saído de sua cidade natal, sendo o crime que lhe foi imputado fato isolado e excepcional. Não há como ser acolhido tal pleito.

Com efeito, o acusado limitou-se a afirmar, sem no entanto trazer aos autos elementos mínimos comprobatórios de sua alegação, de que teria sido constrangido por um indivíduo não identificado, em troca de proteção contra terceiros que o estariam ameaçando, a transportar drogas da cidade de Campo Grande/MS para sua cidade, o Município de Paraupabas/PA. A defesa não arrolou testemunhas que corroborassem tal alegação. Ademais, sequer há notícias de que o acusado teria reportado as supostas ameaças ou intimidações para a Autoridade Policial local. Embora não prevista expressamente no ordenamento legal, a inexigibilidade de conduta diversa configura causa de exclusão da culpabilidade (excludente supralegal) aceita pela doutrina e pela jurisprudência quando houver prova, absoluta e incontestável, da impossibilidade do agente evitar o cometimento do injusto (fato típico e ilícito) sem gravíssimo prejuízo a outro direito relevante. Em outras palavras, deve estar evidenciado que o agente, no caso concreto, não poderia evitar a prática de um ato em desconformidade com a ordem jurídica. Conforme acima destacado, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "Não cabe à acusação demonstrar

e comprovar elementares que inexistem no tipo penal, de forma que o ônus da prova da impossibilidade de repasse das contribuições previdenciárias apropriadas ante às dificuldades financeiras da empresa, a evidenciar, assim, a inexigibilidade de conduta diversa - causa supralegal de exclusão da culpabilidade -, é da defesa, a teor do art. 156 do CPP. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.178.817/SC, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 18/10/2011, DJe de 3/11/2011 - grifo meu). No mesmo sentido: REsp n. 881.423/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 15/3/2007, DJ de 23/4/2007.

Esse é também o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação Criminal 0068177-80.2011.8.26.0050; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/09/2012; Data de Registro: 26/09/2012; Apelação Criminal 0021615-46.2009.8.26.0482; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2010; Data de Registro: 01/12/2010.

6. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do(a) acusado(a).

7. A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do § 2º, do artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Tóxicos não exige que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia para que sua conduta seja enquadrada no tipo penal do artigo 33, caput. Isso porque o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas").

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, "para alicerçar a pretendida condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (TJSP; Apelação Criminal 1500705-48.2018.8.26.0274; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019 - grifo meu).

Ademais, a condição de usuário ou dependente de drogas não é incompatível com a figura do traficante, tampouco afasta per si a imputabilidade do agente. Nesse sentido: TJMS, HC 01733320620158110000, Relator: Desembargador Gilberto Giralddelli, DJ 04/02/2016; TJDF, APR 0015443-41.2008.807.0001, Relator: Desembargador Souza e Ávila, DJ 03/02/2010.

In casu, a quantidade de entorpecentes apreendida (13,995kg de maconha) e sua forma de acondicionamento (em diversas porções, que facilitam o transporte e comercialização) revelam a intenção do(a) denunciado(a) de praticar a traficância ilícita.

Com efeito, conforme se extrai de julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo: a) um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5g a 1,0g do entorpecente; b) uma "fileira" de cocaína é confeccionada com 0,1g a 0,125g da droga, aproximadamente; c) uma pedra de crack tem, em média, 0,2g a 0,25g. Confira-se: Apelação Criminal 1500949-81.2019.8.26.0228; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019; Apelação Criminal 0000617-39.2016.8.26.0247; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018; Apelação Criminal 0000244-11.2015.8.26.0613; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016. Com base nesses dados, conclui-se que a quantidade de droga apreendida (13,995kg de maconha) seria suficiente para produzir diversas porções individualizadas, ou seja, era destinada a entrega a consumo de terceiros. Cabe ainda ressaltar que o réu confessou que estava transportando a vultosa quantidade de estupefaciente para entrega a consumo de terceiros, e não para consumo próprio.

7. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa. In casu, embora primário e portador de bons antecedentes o acusado se dedica à prática de atividades criminosas, porquanto foi apreendido em seu poder significativa quantidade de substâncias entorpecentes, a saber 13,995kg de maconha. Conforme vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a dedicação à atividade criminosa" (AgRg no HC 313.158/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017 - grifo meu). Ademais, restou demonstrado que o sentenciado transportou, de um Estado para outro da Federação, com o objetivo de venda e entrega a consumo de terceiros, 13,995kg de maconha. De acordo com o STJ, o delito de tráfico interestadual inviabiliza a incidência da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Com efeito, a majorante do inciso V, do artigo 40, da Lei n.º 11.343/2006 é incompatível "com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa, motivo pelo qual não há como ser aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (STJ - AgRg no HC 408.476/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018).

II.3 - Da dosimetria das penas

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação

idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

No caso dos autos, verifico que as circunstâncias que envolveram o crime (modus operandi empregado pelo agente, local e horário da prática delituosa) foram gravosas, porquanto excederam o que normalmente se observa nos casos em que é praticado o crime em questão. Com efeito, foi apreendida grande quantidade de drogas (13,995kg de maconha), cabendo destacar que outros elementos foram utilizados para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, a saber: tráfico interestadual. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “Não há bis in idem quando, embora tenha sido valorada a quantidade de droga na primeira e na terceira etapa do cálculo da pena, há outros elementos dos autos que, por si sós, evidenciam a habitualidade delitiva do agente” (STJ – HC 397.875/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, j. 27/06/2017 – grifo meu).

Considerando-se que foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, a saber, 13,995kg de maconha, aumento a reprimenda em 1/3 e estabeleço a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Reconheço as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a reprimenda em 1/3 e estabeleço a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, atentando para o enunciado da Súmula n.º 231 do STJ.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 398 – grifo meu).

Reconheço a majorante prevista no artigo 40, inciso V da Lei n.º 11.346/2006, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6. Fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento no artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime semiaberto, a vultosa quantidade de drogas apreendidas (13,995kg de maconha), bem como a majorante do tráfico interestadual indica(m) que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o acusado já foi contemplado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, prevalece no STF e no STJ o entendimento de que o sursis é inaplicável aos crimes hediondos ou equiparados, pois a dimensão do benefício não se coaduna com a natureza do delito, em relação ao qual a própria CF, em seu artigo 5º, XLIII, determinou tratamento mais severo (STF, HC 101.919/MG; STJ, HC 197.268/SP).

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o(a) acusado(a) MARCOS ALVES TEIXEIRA como incurso(a) nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do(a) acusado(a) e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, que continua necessária para garantia

da ordem pública.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: "HABEAS CORPUS - Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal - [...] Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência - Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada [...]". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2262474-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020 - grifo meu).

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final. Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir prejuízo material constatado.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88;

Porque não interessa a preservação das drogas apreendidas, oficie-se, determinando a incineração delas, mediante termo circunstanciado.

Demonstrado que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, decreto seu perdimento em favor da União Federal, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Penápolis, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA